

《【문제3】 재소의 금지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제3> 재소의 금지의 의의, 요건, 예외, 효과, 특수한 경우의 재소금지

I. 문제의 제기

- 재소의 금지란 소송이 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 자는 동일한 소를 제기하지 못한다는 원칙을 말한다.(민사소송법 제267조 제2항) 이는 국가의 재판권 행사에 의하여 얻은 본안판결이 당사자의 무책임한 소취하로 인하여 농락당하는 것을 방지하고, 법원의 판결을 존중하며 소송경제의 효율성을 도모하기 위한 제도이다. 기판력과는 달리 판결의 확정 전이라도 중국판결 후 소를 취하하면 발생하며, 소송요건으로서 법원의 직권조사 사항에 해당한다. 이하에서는 재소금지의 성립 요건과 그 효과 및 적용 범위에 대하여 구체적으로 살펴본다.

II. 재소금지의 요건 ★

1. 본안에 대한 중국판결이 있을 것

- 재소금지가 적용되기 위해서는 적어도 제1심 또는 상소심에서 본안에 대한 중국판결이 선고된 이후여야 한다. 본안판결이란 청구의 당부에 관한 판결을 의미하며, 소각하 판결과 같은 소송판결은 포함되지 않는다.

2. 소의 취하가 있을 것

- 원고가 중국판결 선고 후 판결이 확정되기 전에 소를 취하하거나, 소취하 간주(민사소송법 제268조)가 성립해야 한다. 상소심에서 소를 취하한 경우 제1심 판결은 실효되나, 재소금지의 제재를 받게 된다.

3. 전소와 후소가 동일한 소일 것

- 재소금지의 효과를 받는 후소는 전소와 동일한 소여야 한다. 동일한 소인지 여부는 당사자, 소송물, 그리고 재소의 필요성이라는 관점에서 판단한다.

(1) 당사자의 동일

- 원칙적으로 전소의 원고가 후소의 원고인 경우를 의미한다. 다만, 전소 원고의 포괄승계인이나 소송담당에서의 채무자 등 실질적 이해관계가 동일한 자에게도 재소금지의 효력이 미친다.

(2) 소송물의 동일

- 전소와 후소의 소송물이 동일해야 한다. 다만, 청구취지가 다르더라도 소송물이 동일하거나, 전소의 기각을 면하기 위해 외형상 형태만 바꾼 경우 등은 동일한 소로 간주될 수 있다.

III. 재소금지의 예외 : 권리보호의 이익

1. 새로운 사정의 발생

- 중국판결 후 소를 취하했다라도 후소를 제기할 만한 정당한 사유가 있는 경우에는 재소금지에 저촉되지 않는다. 전소 취하 후에 발생한 새로운 사정으로 인하여 다시 소를 제기할 권리보호의 이익이 생긴 경우를 말한다.

2. 소권 행사의 오남용이 없는 경우

- 재소금지의 취지가 재판권의 오남용 방지에 있으므로, 당사자가 법원을 농락하려는 의사 없이 불가피한 사정으로 소를 취하했다가 다시 제기하는 경우에는 확인의 이익이나 재소의 필요성을 긍정하여 예외를 인정할 수 있다.

IV. 재소금지의 효과

1. 소송요건과 각하 판결

- 재소금지는 소송요건 중 하나이므로 법원은 이를 직권으로 조사하여야 한다. 재소금지에 위반된 소제기는 부적법하므로 법원은 본안에 대한 심리를 하지 않고 판결로써 소를 각하하여야 한다.

2. 기판력과의 구별

- 기판력은 판결의 확정을 요하나, 재소금지는 중국판결 후 소취하 사실만으로 발생한다. 또한 기판력은 본안판결의 내용을 존중하는 것이 목적이지만, 재소금지는 소취하에 의한 법원 농락 방지를 주된 목적으로 하는 제재적 규정이다.

V. 특수한 경우의 재소금지

1. 소의 변경과 재소금지

- 교환적 소변경의 경우 실질적으로 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 형태이므로, 중국판결 후 교환적으로 소를 변경한 경우 구소에 대해서는 재소금지의 원칙이 적용될 수 있다.

2. 독립당사자참가와 재소금지

- 독립당사자참가 소송에서 본안판결 후 원고가 소를 취하한 경우, 참가인의 청구와 관계없이 원고는 동일한 소를 제기할 수 없다. 이는 소송의 형태와 무관하게 제재적 성격이 유지되기 때문이다.

VI. 결론

- 재소금지 원칙은 당사자의 처분권주의를 존중하면서도 국가 재판권의 효율적 운영과 법적 안정성을 수호하기 위한 장치이다. 특히 중국판결이라는 국가적 노력이 투입된 이후의 소취하에 대해 엄격한 제재를 가함으로써 소송절차의 신의칙을 구현한다. 다만, 당사자의 정당한 권리 행사가 부당하게 위축되지 않도록 새로운 사정이나 재소의 필요성을 엄격히 해석하여 구체적 타당성을 확보하는 운용이 필요하다.